InDret

# *Codificación civil y competencia legislativa de la Generalitat de Catalunya*

**Joan Egea Fernández**
**Facultad de Derecho**
**Universitat Pompeu Fabra**

**Working Paper de Dret Català nº: 8**
**Barcelona, octubre de 2003**
**www.indret.com**

## *Abstract*

*La Ley 29/2002, de 30 de diciembre. Primera Llei del Codi civil de Catalunya, es la manifestación más clara de la voluntad del Parlament de Catalunya de culminar, al más alto nivel posible, el proceso de desarrollo del derecho civil catalán. A ello se ha opuesto el gobierno del Estado con la interposición, el pasado 10 de abril de 2003, de un recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada Ley. El recurso cuestiona la constitucionalidad de la técnica de un código civil para Cataluña basándose en la atribución de una función casi constitucional al Código Civil español como limitador de las competencias de la Generalitat. En este trabajo se sostiene, por el contrario, que la Constitución en ningún momento reconoce este papel al Código y que la opción codificadora, en sí misma considerada, no puede resultar inconstitucional ya que una simple técnica legislativa, en principio, no puede invadir las competencias que el artículo 149.1.8ª CE reserva 'en todo caso' al Estado.*

## *Sumario*

**1. El Código civil de Cataluña: seguridad jurídica, simplificación normativa y reputación**
**2. El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 29/2002, de 30 de diciembre. *Primera Llei del Codi civil de Catalunya*: el anacronismo de fundamentar la interpretación del art. 149.1.8ª CE en los postulados decimonónicos de la unificación civil**
**3. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional**
**4. Constitucionalidad de la *Primera Llei del Codi civil de Catalunya***

## *1. El Código civil de Cataluña: seguridad jurídica, simplificación normativa y reputación*

El 13 de enero de 2002, el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* (núm. 3798) publicaba la Ley 29/2002, de 30 de diciembre. *Primera Llei del Codi civil de Catalunya*, que diseña la estructura, el contenido y el procedimiento de tramitación del Código, a la vez que aprueba el Libro primero. Con la adopción de la técnica de un código general, el *Parlament* da un paso muy importante hacia la equiparación del ordenamiento civil catalán con los de su entorno y abandona la vía de la codificación sectorial que, no hace mucho, llevó a los códigos de sucesiones y de familia, descartando, así, completar la elegida con el Código de derecho patrimonial. De hecho, el pasado 23 de junio, el gobierno de la Generalitat ya acordó presentar al *Parlament* el proyecto de *Segona Llei del Codi civil de Catalunya* relativo al Libro quinto, sobre los derechos reales (BOPC núm. 451, de 30 de julio), aunque, a día de hoy, al haberse publicado ya el Decreto de disolución del *Parlament* y de convocatoria de elecciones para el próximo 16 de noviembre, esta iniciativa ha quedado en un simple gesto.

> Aunque algunos autores (ROCA SASTRE , *Estudios de derecho civil especial de Cataluña.* Barcelona, 1983, pág. 1) hayan considerado que la Compilación de Derecho Civil Especial de Cataluña de 1960 participaba de la naturaleza de los códigos porque, apartándose de la técnica recopiladora, adoptaba un esquema muy parecido al del propio Código español, es extremadamente forzado afirmar que esto es así. Efectivamente, incluso dejando de lado su propio nombre y prescindiendo también de que, de acuerdo con el Decreto de 23 de mayo de 1947, por el cual se crean las Comisiones de juristas para el estudio y la ordenación de los derechos forales, las compilaciones habían de ser el primer paso hacia un código único para toda España, lo cierto es que aquella Compilación no iba más allá de una simple agrupación incompleta de las antiguas leyes simplificadas y sistematizadas, y que quedaba muy lejos de los auténticos códigos. Es más, en su tramitación parlamentaria, el texto fue drásticamente recortado por las cortes franquistas, cosa que en el preámbulo se justifica diciendo que "*[n]o ha recogido algunas normas vigentes en Cataluña, que presentaban ligeras variantes* [refiriéndose al Código civil]". Igualmente, el hecho de que partiese de que "*[l]a especialidad es la nota característica de estas Compilaciones, sin que, por tanto, sean aconsejables enmiendas a la Ley común*", dejaba claro que no pretendía ser un código en sentido propio; la ley común seguía siendo el Código civil español, del que la Compilación era sólo una simple especialidad a la espera de aquel anunciado código general para toda España, que ya nunca llegaría.

Si exceptuamos el corto paréntesis de la Segunda República, no fue hasta la Constitución de 1978 y el subsiguiente *Estatut d'Autonomia de Catalunya* de 1979 cuando se fijó un nuevo marco normativo que, en el ámbito civil, posibilitó que Cataluña recuperase la capacidad legislativa perdida en el siglo XVIII con la derrota ante las tropas de Felipe V. La técnica legislativa utilizada a lo largo de estos más de veinticinco años de autonomía legislativa ha sido bastante heterogénea: inicialmente, se optó por las leyes especiales, combinadas con las de reforma de la Compilación; después, sin abandonar del todo las leyes especiales, se pasó a la codificación sectorial de los tres grandes bloques del derecho civil: sucesiones, familia y patrimonial; y ahora, descartado el Código de derecho patrimonial, se ha iniciado directamente la vía del Código civil de Cataluña. Hay que mencionar, sin embargo, que en el horizonte del legislador catalán pronto se dibujó el objetivo de que toda aquella legislación dispersa y también los Códigos sectoriales eran simples herramientas que debían facilitar el tránsito hacia un Código civil de Cataluña. Éste, finalmente, se ha concebido como un **código abierto**, que se tiene que ir elaborando mediante sucesivas leyes seriadas, con lo

que se facilita el dar una respuesta más ágil a los cambios sociales que inevitablemente se van produciendo, ya sea mediante su reforma o incorporando instituciones aún no reguladas, sin forzar su estructura ni sistemática.

Desde esta perspectiva, resulta bastante claro que el Código civil de Cataluña, como el resto de códigos modernos, desarrolla una función que no tiene demasiado que ver con la codificación decimonónica, ya que hoy en día la técnica codificadora no debe considerarse como un instrumento que contribuya de forma determinante a la modernización de las estructuras sociales y económicas, sino que éste es un papel que, en sus líneas fundamentales, lo desarrollan las constituciones modernas. Efectivamente, ni, en su momento, los códigos de familia y de sucesiones, ni ahora tampoco el Código civil de Cataluña responden a la concepción político-filosófica de los códigos del siglo XIX, sino que están más cerca de las llamadas *leyes consolidadoras* (N. IRTI, 1986, 2ª, 59), en el sentido de que todos los sistemas jurídicos, grandes o pequeños, están regidos por la lógica de las leyes especiales y tienden hacia las leyes consolidadoras o los textos refundidos. Esto es, ambos códigos vinieron a refundir en los respectivos cuerpos normativos las diversas leyes especiales anteriormente aprobadas por el *Parlament* y ahora la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, va más allá y se propone sistematizar toda la normativa civil catalana en un solo texto legal. Por ello, al especificar el concreto proceso de elaboración, el art. 6.4 de la Primera Ley dispone que, si procede, cada ley de la serie contendrá una disposición final que autorice al gobierno a refundir, mediante Decreto Legislativo, las modificaciones que deriven de las normas y disposiciones que continúen sin alteración.

> Lógicamente, el Libro sexto relativo a las obligaciones y a los contratos es el que debe plantear más dificultades en su elaboración, ya que ésta es una materia sobre la que, prácticamente, no ha habido desarrollo legislativo y, además, será necesario ajustarla a unas bases de las obligaciones contractuales, que el legislador estatal todavía no ha definido.

Lejos, pues, de aquellas funciones constitucionales, el Código simplemente pretende ser una buena herramienta para alcanzar un objetivo tan sencillo, pero a la vez tan útil y fundamental para el futuro del derecho civil de Cataluña, como es el de garantizar su efectiva aplicabilidad; y ello por las siguientes razones:

a) Su *utilidad*: una vez se haya completado su redacción, el Código permitirá a los operadores jurídicos encontrar reunido y sistematizado todo el derecho civil de Cataluña (disperso, actualmente, en unas veinticinco leyes) cosa que deberá traducirse, necesariamente, en una mayor frecuencia en la alegación por los abogados y en la aplicación judicial. Esto quiere decir también más *seguridad jurídica*.

b) La *simplificación y la unificación de estilo*: se evitan reiteraciones y remisiones externas, que en cambio son imprescindibles cuando la regulación aparece dispersa en leyes especiales. Paralelamente aumenta la calidad de la ley.

c) La *reputación*: el derecho codificado se percibe por los operadores jurídicos y por los ciudadanos en general como un derecho más reputado que proporciona mejor consideración a un ordenamiento.

Todas estas ventajas no se ven disminuidas, al menos sustancialmente, por el hecho de que el vigente sistema constitucional de distribución de competencias no permite que el Código civil de Cataluña pueda llegar a englobar la totalidad de la materia civil (recordemos que el art. 149.1.8ª CE reserva al Estado, "en todo caso", la competencia exclusiva sobre reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales y normas para resolver los conflictos de leyes).

En fin, salvando, claro está, cual sea el concreto desarrollo que se haga de cada institución, la técnica de la codificación civil, por sí misma considerada, no puede implicar la invasión de competencias del Estado ni, aún menos, la vulneración de ningún principio constitucional. Dicho esto, en este paper se exponen los argumentos con los que pretendemos demostrar la falta de fundamento de la pretensión del gobierno del Estado de que se declare la inconstitucionalidad de la totalidad de la p *Primera Llei del Codi civil de Catalunya*, y se sostiene que la Generalitat tiene plena competencia para aprobar su propio Código civil.

## *2. El recurso de inconstitucionalidad contra la Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera Llei del Codi civil de Catalunya: el anacronismo de fundamentar la interpretación del art. 149.1.8ª CE en los postulados decimonónicos de la unificación civil*

El 10 de abril de 2003, el gobierno del Estado interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, porque entiende que invade sus competencias y ha invocado, además, la aplicación del art. 161.2 CE, para suspender su vigencia; subsidiariamente, ha dirigido también el recurso contra treinta y dos de los treinta y ocho artículos del Libro primero del Código civil de Cataluña. En este trabajo me centraré, fundamentalmente, en la **pretensión principal** de que se declare inconstitucional la totalidad de la ley, porque en el fondo, como decía, aquello que el gobierno quiere es negar la competencia de la Generalitat para aprobar un código civil.

Sustancialmente, los argumentos que el recurso utiliza para fundamentar la falta de competencia son dos:

- que la Ley 29/2002 determina la no-aplicación, con carácter general, del derecho del Estado a Cataluña, que en el propio recurso se califica de derecho civil común,

- que afecta a *"las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas"*, que, recordemos, es una materia que el art. 149.1.8ª CE atribuye en todo caso a la competencia estatal.

De aquí deriva la conclusión que la ley impugnada *"supone la implantación de un régimen distinto del actualmente vigente en el Código Civil en materia de derecho privado..."* y, más adelante, sorprendentemente, añade que *"manifiesta una pretensión codificadora que resulta incompatible con la Constitución, al tratar de establecer un régimen jurídico de Derecho civil para Cataluña completo e independiente del Derecho civil común estatal"*, como si no fuese precisamente esto lo que permite la propia Constitución (completo e independiente, claro está, dentro del marco competencial constitucionalmente previsto). Pero es que, por el contrario, no hay nada más opuesto a la estructuración jurídico-civil prevista en la vigente Constitución que la mencionada *"[u]nidad del ordenamiento jurídico español"*, ya que este criterio de la unidad difícilmente se aviene con otorgar competencia legislativa a la Generalitat de Cataluña para desarrollar el derecho civil catalán: se olvida que el art. 149.1.8ª CE ha constitucionalizado la diversidad legislativa civil, con el límite de aquello que en todo caso corresponde al Estado.

De hecho, si nos ceñimos al protagonismo que en éste y en los anteriores recursos de inconstitucionalidad contra leyes civiles se está otorgando al Código civil español, la conclusión que se desprende es que el gobierno del Estado hace una lectura del texto constitucional que sigue anclada en una concepción del ordenamiento civil casi preconstitucional, como si la etapa de las compilaciones todavía no se hubiese superado.

Es cierto que el recurso admite, por lo menos formalmente, que la Constitución de 1978 cambió las premisas que regían el derecho civil denominado común y el propio de los llamados territorios forales, pero también lo es que, en la práctica, se propugna una drástica reducción del alcance de este modelo de autonomía legislativa con base a una anacrónica interpretación histórica del art. 149.1.8ª CE que pretende apoyarse en la unidad legislativa perseguida por el movimiento codificador decimonónico. De aquí que una y otra vez se aluda a un pretendido principio de *"la unidad del ordenamiento jurídico"* que hoy no tiene ninguna base constitucional, al menos en el sentido que se deduce de toda la argumentación del recurso.

> Queriendo reforzar los argumentos a favor de esta pretendida unidad del ordenamiento, el recurso se remonta a la baja edad media, cuando en la península y en Europa regía el *ius commune*. Esta cita histórica, sin embargo, más bien denota una cierta voluntad de instrumentalización, ya que de ella saca la conclusión que, en virtud del Decreto de Nueva Planta, la función de derecho común pasó a ser desarrollada por el derecho real de Castilla (Partidas y Nueva Recopilación) y es sabido que esto no fue así, al menos para el derecho civil de Cataluña, puesto que en el Principado, a diferencia del reino de Castilla, no se materializó el derecho romano en un texto propio, sino que el *ius commune*, tal y como disponía la Constitución de Felipe II en las Cortes de Barcelona de 1599 (CiADC I, I, XXX, I), siguió siendo el supletorio del catalán hasta el año 1960.

El ideal unificador del siglo XIX y su plasmación casi en todas las constituciones españolas de la época, no puede servir de criterio interpretativo del actual art. 149.1.8ª CE, entre otras razones, fundamentalmente, porque este precepto dibuja un sistema de distribución competencial que se

contrapone a cualquier pretensión unificadora. No debe olvidarse, además, que fue precisamente en la época de la Restauración borbónica, cuando la insistente reacción de los juristas catalanes oponiéndose a un Código civil único para toda España llevó, en el año 1889, a que el Código civil acabase siendo el del derecho histórico de Castilla (siguiendo el modelo del Proyecto de 1851) y a que los territorios donde subsistía el llamado derecho foral lo conservasen "*por ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico, escrito o consuetudinario, por la publicación de este Código, que regirá tan sólo como derecho supletorio en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas por sus leyes especiales*". Además, el objetivo de un código civil único para toda España que excluyese la aplicación de los derechos territoriales no llegó a conseguirse nunca, si exceptuamos algunas materias concretas que fueron objeto de leyes especiales de aplicación general a toda España, después de la revolución de 1868, que supuso el destronamiento de Isabel II.

Pero, incluso aceptando que recurra a la interpretación histórico-constitucional, lo que más sorprende del recurso es que pase totalmente por alto cualquier referencia a la Constitución de la segunda República (9 de diciembre de 1931) que fue la que permitió que Cataluña recuperase su capacidad legislativa perdida hacía más de dos siglos, y más aún si tenemos en cuenta que su artículo 15 fue el que sirvió de modelo para la redacción del vigente art. 149.1.8ª de la Constitución de 1978.

> El art. 15 de la Constitución republicana, por lo que concierne a la legislación civil, sencillamente atribuía al Estado la competencia sobre "*la forma del matrimonio, la ordenación de los registros e hipotecas, las bases de las obligaciones contractuales y la regulación de los Estatutos personal, real y formal para coordinar la aplicación y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones civiles de España*". En el resto de materias –añadía el art. 16-, la legislación exclusiva y la ejecución directa "*podrán corresponder a la competencia de las regiones autónomas... conforme a lo que dispongan los respectivos Estatutos aprobados por las Cortes*". En esta línea el art. 11 del *Estatut de Catalunya* de 1932 atribuyó a la Generalitat "*la legislació exclusiva en matèria civil, llevat el que es disposa a l'art. 15 núm. 1 de la Constitució...*".

Es innecesario recordar, por ampliamente conocido, que esta etapa de autonomía legislativa fue abortada por el régimen franquista, que derogó el *Estatut* y dejó sin efecto todas las leyes del *Parlament de Catalunya* y la doctrina del Tribunal de Casación; esto condujo, irremediablemente, a la situación anterior al año 1931, es decir, a la que diseñó el Código civil de 1889, volviendo, pues, a la provisionalidad del mantenimiento de los derechos forales o especiales, que perduraría hasta el Decreto Legislativo 1836/1974 que aprobó el nuevo Título Preliminar del Código civil, que vino a derogar el originario art. 12.2 CC y, con él, la expresión "*lo mantendrán por ahora*".

En el ínterin, el Decreto de 23 de mayo de 1947, que tuvo su origen en las conclusiones del *Congreso Nacional de Derecho civil* celebrado en Zaragoza en octubre de 1946, había cambiado el sistema de Apéndices por el de las Compilaciones, sin que esto, sin embargo, supusiese el abandono, en ningún sentido, de la idea de refundirlas en un Código civil único para toda España. A partir de aquí, la Comisión de juristas catalanes redactó un texto de 569 artículos que fue revisado y finalmente reducido hasta los 344 artículos, que son los que acabarían integrando la Ley de 20 de julio de 1960. He realizado este breve recorrido histórico para destacar la

coyuntura en que fue aprobada la compilación y como, prescindiendo de ello, es paradójicamente el texto que desde el gobierno del Estado se pretende casi sacralizar y convertir en el eje sobre el que ha de girar la competencia de la Generalitat en materia civil. Para ello se fundamenta, sin embargo, en una interpretación sesgada e interesada, ya que la referencia que el art. 149.1.8ª CE hace al *"allí donde existan"* no implica ningún límite material de competencias ni impide que se pueda ir más allá de las normas compiladas, sino que sólo constituye un criterio para determinar qué Comunidades Autónomas pueden legislar en materia civil; el único límite que la Constitución establece para el desarrollo legislativo autonómico es el de las materias que "en todo caso" son competencia del Estado. No es éste, sin embargo, el criterio que sigue el Tribunal Constitucional, que, como más adelante mencionaré, parece decantarse también por una interpretación correctora (restrictiva) de este precepto constitucional, que entiende que la competencia sobre desarrollo de los denominados derechos forales (más correctamente de las CCAA con competencia civil) exige una conexión institucional entre el derecho compilado y la nueva norma. Las compilaciones se convierten así en un límite material al desarrollo legislativo civil que la Constitución no prevé.

Tendría que bastar con una interpretación literal del artículo 149.1.8ª CE para comprobar que éste perfila una estructura del ordenamiento civil del Estado y un ámbito competencial en materia civil muy parecidos, al menos desde una perspectiva objetiva, a la que en su momento establecieron los arts. 15 y 16 de la Constitución republicana de 1931. Tal vez la diferencia más notable sea la del número de Regiones (Comunidades) autónomas que tienen reconocida dicha competencia: los arts. 15 y 16 de la Constitución de 1931 la atribuían a *todas* las regiones autónomas (de acuerdo, claro está, con lo que establecieran sus respectivos Estatutos), mientras que la Constitución actual sólo la reconoce a las Comunidades en los territorios de aquéllas en las que "*existan*" derechos civiles forales o especiales. Con ello quiero hacer notar que el hecho de que ahora el art. 149.1.8ª CE ubique la materia civil dentro del listado de competencias que corresponden al Estado no es argumento suficiente, como veremos a continuación, para entender que se ha producido un cambio de criterio, sino que esta diferencia sistemática se debe, sencillamente, a que sólo las Comunidades Autónomas con derecho propio son competentes para legislar en materia civil.

> Que el art. 16 de la Constitución de 1931 afirmase que el resto de materias civiles no atribuidas al Estado "*[p]odrán corresponder a la competencia de las regiones autónomas*", sin concretar –como, en cambio, sí concreta el art. 149.1.8ª CE- que esta competencia es para la "*conservación, modificación y desarrollo"*, no permite concluir que existan diferencias sustanciales entre lo que disponen el uno y el otro.

Precisamente, el hecho de que no todas las Comunidades Autónomas tuviesen derecho civil propio es lo que determinó que la Constitución de 1978 ubicase la materia civil en el art. 149 CE (que es donde se enumeran las competencias del Estado), y no en el art. 148 CE (que contiene el listado de competencias de las CCAA), a pesar de que ésta hubiese sido la ubicación más adecuada. Esto es lo ha dado pie a las interpretaciones más restrictivas para la competencia autonómica y lo que llevó a utilizar la fórmula *"sin perjuicio del derecho civil foral o especial"*, que obviamente presupone que las Comunidades con derecho civil propio pueden tener atribuida estatutariamente esta competencia.

El sistema constitucional español se estructura, por tanto, en una pluralidad de ordenamientos civiles con ámbitos de aplicación propios y, por tanto, no se puede decir que exista una unidad del ordenamiento civil, más allá de la que resulta del hecho que todos ellos se sitúen al abrigo de la Constitución; pero, como vemos, no es precisamente éste el concepto de unidad del ordenamiento que se discute en el recurso. El hecho que el derecho civil del Estado cumpla la doble función de ser de *aplicación general y directa* (en aquello que se refiere a las materias excluidas de la competencia autonómica que están atribuidas en todo caso al Estado) y de *aplicación supletoria*, en la parte todavía no normatizada por el derecho autonómico en el ámbito de la propia competencia de la Generalitat, no debe identificarse con que rija un pretendido principio de unidad del ordenamiento jurídico español, sino todo lo contrario: la supletoriedad implica la heterointegración y ésta se da, precisamente, cuando existe pluralidad legislativa.

Esta errónea concepción unitaria del ordenamiento civil y la consiguiente interpretación restrictiva de la competencia de la Generalitat en materia civil se tradujeron, ya hace unos cuantos años, en la interposición por el Estado de sendos recursos de inconstitucionalidad contra la *Llei 9/1987, de 25 de maig, de successió intestada* i contra la *Llei 7/1991, de 27 d'abril, de filiacions*, que generaron una fuerte reacción de las entidades jurídicas catalanas, a consecuencia de esto (y sobre todo, no hace falta decirlo, de la negociación política) el gobierno del Estado los retiró. A partir de este momento se entró en la etapa más prolífica en materia de legislación civil por parte del Parlament de Catalunya (desde el año 1991 hasta el 2002, se han aprobado unas dieciséis leyes civiles) sin que haya habido ningún tipo de oposición por parte del Estado; no obstante, ahora se han interpuesto tres recursos de inconstitucionalidad en poco menos de un año: uno contra tres de los artículos de la *Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l'accessió i l'ocupació;* otro contra ocho artículos de la *Llei 19/2002, de 5 de juliol de drets reals de garantia* i, últimamente, tan solo hace cinco meses, contra la totalidad de la *Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera Llei del Codi civil de Catalunya*, con creces, la más importante de todas las leyes civiles que ha aprobado el *Parlament*. Esto último, además, tiene una especial significación, porque como ha quedado mencionado, lo que realmente viene a cuestionar es que Cataluña pueda adoptar la técnica de un Código civil. De hecho la propia petición subsidiaria persigue indirectamente la misma finalidad de dejar inoperante toda la ley por la vía de impugnar la práctica totalidad de los artículos que integran el Libro I, y, por si no habían quedado suficientemente claras sus intenciones, solicita también la suspensión inmediata de su vigencia.

## *3. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional*

Decía antes que el Tribunal Constitucional parece haberse decantado también por una interpretación muy restrictiva del art. 149.1.8ª CE, aunque todavía deja un cierto margen de flexibilidad, ya que la lectura que de este precepto se ha hecho, por ejemplo en la STC 88/1993 (FJ 1º) [que reitera después en la STC 156/1993 de 6 de mayo] es que se trata de una norma que introduce una "*garantía de la foralidad civil*", en el sentido de que "*[l]a Constitución permite, así, que los derechos civiles especiales o forales preexistentes puedan ser objeto [...] de una acción legislativa que*

*haga posible su crecimiento orgánico...*", admitiendo, además, que "*[n]o debe vincularse rígidamente al contenido actual de la Compilación u otras normas de su ordenamiento*". Hasta aquí, éste es un planteamiento que, a primera vista, permite concluir que la competencia autonómica en materia civil no tiene ningún límite más que lo que, en todo caso, corresponde al Estado; ahora bien, obsérvese que cuando afirma que la competencia autonómica no se debe vincular rígidamente al contenido actual de la Compilación, viene a decir 'a contrario', que se podría afirmar que hay otra vinculación (no rígida), que el propio Tribunal Constitucional acaba identificando con la *exigencia de una conexión* entre las instituciones compiladas y la nueva norma. Más específicamente la mencionada sentencia 88/1993 afirma que:

> "*[C]abe, pues, que las Comunidades Autónomas dotadas de Derecho civil foral o especial* ***regulen instituciones conexas*** *con las ya reguladas en la Compilación dentro de una actualización o innovación de los contenidos de ésta según los principios informadores peculiares del Derecho foral*".

Una consecuencia clara e inmediata de esta exigencia es que cuanto más detallada sea la regulación institucional que haga una determinada Compilación, más posibilidades de conexión habrá entre el derecho que se desarrolla y el compilado y, por tanto, también más posibilidades de acabar perfilando un ordenamiento civil completo. Ésta es una interpretación que quita cualquier tipo de trascendencia al hecho de que la diferente extensión de cada compilación es tributaria del concreto momento político del régimen franquista en que fue aprobada (es más completa, por ejemplo, la compilación navarra, aprobada el año 1973, cuando la dictadura estaba ya acabando, que las primeras, como la catalana, que fue aprobada el 1960).

> Una prueba palpable de lo que esta interpretación restrictiva significa la encontramos, precisamente, en la parte del recurso que pide que se declare inconstitucional casi toda la regulación de la prescripción (excepto los arts. 121-20, 121-21 y 121-22 que son, precisamente, los que fijan los diferentes plazos – decenal, trienal y anual), es decir, las normas que más bien tocan cuestiones tangenciales de la prescripción, como la necesidad de que sea alegada, la posibilidad de renuncia, la interrupción, la suspensión, etc. ¿Es que no hay conexión entre los plazos de la prescripción y la regulación de su régimen jurídico?

Con todo, hay que ser optimistas y pensar que el criterio de las "*instituciones conexas*" es suficientemente indeterminado como para considerar que se trata únicamente de un expediente de que se vale el Tribunal Constitucional para poder modular más ampliamente o más restrictivamente, según convenga, la competencia legislativa civil de cada concreta Comunidad Autónoma, y, aisladamente considerado, es suficientemente flexible para admitir una competencia de la Generalitat de Catalunya bastante amplia. Este optimismo, decae sin embargo por el hecho de que, de momento, el Tribunal Constitucional no está dejando mucho camino por recorrer, ya que al final advierte que la indeterminación del concepto "institución conexa", "*[n]o significa claro está... una competencia legislativa ilimitada* ratione materiae *dejada a la disponibilidad de las Comunidades Autónomas, que pugna con lo dispuesto en el art. 149.1.8ª CE...*". Efectivamente, la competencia no es ilimitada, sino que se debe mantener dentro de los límites, tantas veces citados, en las materias que el art. 149.1.8ª CE atribuye en todo caso a la competencia del Estado.

## *4. Constitucionalidad de la Primera Llei del Codi civil de Catalunya*

La *Llei 29/2002, de 30 de decembre* tiene dos objetivos, y así lo expone en su preámbulo: el primero es *"establir l'estructura, el contingut bàsic i el procediment de tramitació del Codi civil de Catalunya"* i, el segundo *"aprovar el Llibre primer del Codi civil de Catalunya, titulat 'Disposicions generals', el qual, sens perjudici que es pugui ampliar en el futur, s'estructura ara en dos títols"*. El recurso, en su petición principal, pide que la totalidad de la Ley sea declarada inconstitucional; es decir, tenemos que entender que se refiere tanto a la parte que sustenta la estructura del Código, como a la que aprueba su Libro primero. Por tanto, desde el punto de vista de la petición de inconstitucionalidad de toda la Ley, el debate se plantea en unos términos diferentes que los de la existencia o no de conexión entre las instituciones reguladas y las contenidas en el derecho anterior. El Estado cuestiona que la Generalitat de Cataluña pueda emplear la técnica de un código general, presuponiendo, como se ha visto, que con la aprobación del Código se vulnera un supuesto principio constitucional de unidad legislativa que representa el Código civil español; a partir de aquí, el recurso atribuye a la *Primera Llei del Codi civil de Catalunya* el pretendido efecto negativo de eliminar cualquier posibilidad de aplicación del Código español.

Sorprende que una afirmación como ésta se haga en el marco de una Constitución que reconoce la competencia legislativa de determinadas comunidades autónomas para legislar en materia civil, ya que, en este contexto, la unidad únicamente se puede admitir, en todo caso, en el sentido que le da el art. 147.1. CE cuando afirma que los Estatutos de autonomía (y por tanto las normas que de ellos se derivan) son parte integrante del ordenamiento jurídico del Estado, no en el papel de derecho supletorio que pueda corresponder al Código civil. La supletoriedad es en si misma una eventualidad y la aplicación de las normas con este carácter supletorio depende de los vacíos normativos que puedan existir. La Constitución vigente estructura un ordenamiento civil plural, integrado por el Código civil y las leyes civiles del Estado y por los diversos conjuntos normativos civiles de cada una de las autonomías, en un plano de igualdad con el primero y con sus propios principios y ámbito de aplicación. Es este sentido, pues, en el que debemos entender las expresiones "sub-ordenamientos" o "subsistentes" y por tanto no tiene ningún fundamento constitucional ampararse en una pretendida unidad del ordenamiento y en la prevalencia del código español.

Para reforzar esta idea de unidad, el recurso enfatiza la existencia de un *sistema global*, que comprende las normas que no pertenecen a un subsistema, es decir, las que regulan la materia que es competencia exclusiva del Estado (en todo caso), que aquí tampoco discutimos. De hecho la aplicación de las normas que conforman este llamado sistema global no es una cuestión de supletoriedad, sino de derecho aplicable en primer lugar. En efecto, el Código catalán, por definición, no pretende ni puede disciplinar estas materias ni, de hecho, ninguna de sus disposiciones excluye la aplicación de las normas del Código civil español que, yendo más allá del derecho civil, pertenecen a lo que podría llamarse ordenamiento jurídico español como un todo (como puede ser por ejemplo el art. 2 CC en relación con la derogación y la irretroactividad; el art. 3 CC en relación con los criterios generales de interpretación de las normas jurídicas; el art. 4 CC respecto de los límites para la aplicación analógica, etc).

> El fundamento para sostener la inconstitucionalidad de la mayor parte de las disposiciones preliminares es que éstas invaden la competencia exclusiva del Estado sobre *"[...] reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas civiles[...]"*. No es este el lugar, ni el momento, para analizar la falta de solidez de este fundamento, pero no puedo dejar de decir que el contexto es claro: las normas sobre aplicación e interpretación que se contienen en el código catalán tienen por objeto exclusivamente el derecho civil de Cataluña.

En cualquier caso, el tenor de los siete artículos que componen la *Primera Llei del Codi civil de Catalunya*, difícilmente permite concluir que toda la Ley es inconstitucional; por un lado, si se tiene en cuenta que su objeto es establecer la estructura, la sistemática y aprobar el libro primero, no vemos como una estructura básica, ni aún menos la sistemática empleada, pueden infringir las competencias del Estado en materia civil; lo lógico sería que, en su caso, la inconstitucionalidad se predicara del contenido (y de momento, el único contenido normativamente detallado que se conoce es el del libro primero). Puesto que no se ha producido todavía el desarrollo normativo concreto del resto de libros, no hay ninguna valoración de la constitucionalidad de los futuros contenidos.

A pesar de la pretensión de que se declare inconstitucional toda la ley, paradójicamente, el recurso no cita, ni una sola vez, ninguno de los preceptos de la *Llei 29/2002*, sino que se fundamenta exclusivamente en los del *Llibre Primer del Codi civil de Catalunya* que se ha aprobado, eso sí, por el art. 7: concretamente, los argumentos son, por una parte, que el código catalán no nombra *expresis verbis* al Código Civil español como supletorio (art. 111-5), y, por otra, que los principios generales del derecho han pasado a integrarse dentro de las fuentes del derecho civil catalán (art. 111-1 y 111-5), asumiendo la función de suplir sus deficiencias o lagunas, lo que comporta la exclusión de la legislación estatal. Pero en este punto, hay que insistir nuevamente en que el *Llibre primer del Codi* no establece nada diferente de lo que ya establecía la DF 4a de la Compilación; y además, aunque se admitiera la inconstitucionalidad de estas normas, esto no puede repercutir en la inconstitucionalidad de toda la Primera Ley. El Código civil de Cataluña, abstractamente considerado, no puede ser considerado inconstitucional por el solo hecho de que los principios generales del derecho propio se incluyan, ahora expresamente, entre las fuentes del derecho, sino que en el caso hipotético en que se considerara que aquellas normas que los regulan no se ajustan a las previsiones constitucionales sobre la competencia de la Generalitat en materia civil, debería ser suficiente impugnar los preceptos concretos del Libro primero que a se refieren.

> *Esto es lo que pretende la petición subsidiaria al solicitar, como he mencionado previamente, que se declare la inconstitucionalidad de 32 de los 38 artículos que integran el libro primero del Código, a saber: el art. 111-1 apartado 2º, en relación con el sistema de fuentes del derecho; el art. 111-4 que establece el carácter de derecho común del propio código y por conexión el art. 111-5, sobre la preferencia del derecho civil de Cataluña y el papel de filtro que ejercen los principios generales del derecho propio cuando se debe acudir a la aplicación del derecho supletorio; el art. 111-6, que positiviza el principio de libertad civil, el art. 111-7 sobre el principio de la buena fe y la honradez en los tratos; y el art. 111-9 sobre la equidad, todo ello, teniendo en cuenta que también solicita la inconstitucionalidad del Título II, sobre la prescripción y la caducidad (salvo los tres artículos sobre los plazos).*

Es muy sintomático, pues, que la petición principal sea la inconstitucionalidad de toda la Ley y que la subsidiaria afecte prácticamente al ochenta por ciento de los artículos, evidenciando así una clara voluntad de dejar sin contenido lo que realmente debe dar coherencia y unidad al Código y a todo el derecho civil de Cataluña: las disposiciones preliminares. Precisamente, el argumento principal en el que se sustentan ambas pretensiones es –insistimos- la atribución al Código español de un rango que podríamos catalogar de casi-constitucional, en la medida en que el recurrente lo considera una manifestación de la *"unidad básica del derecho civil español"* de la que sólo se pueden excepcionar la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles forales *"[s]in que ello pueda suponer nunca la creación de un sistema jurídico autónomo que inadmita qualquier grado de supletoriedad estatal"*. El recurso sufre una errónea interpretación del art. 149.1.8ª CE, que se fundamenta en la concepción del Código civil español como *"derecho común en el ámbito del Derecho privado en cualquier parte del territorio nacional"*, cuando la realidad es que la única norma constitucional que reserva este papel al Código civil español (la supletoriedad) es el art. 149.3 CE. Ciertamente, podemos decir que el Código español está vigente en todo el Estado como derecho supletorio (cosa que es diferente de su aplicabilidad) y también en la parte que es de aplicación directa. Dicho con otras palabras, no se puede olvidar que, precisamente, lo que permite la Constitución es la creación de sistemas jurídicos autónomos y que la aplicación supletoria sólo depende de lo completo que sea cada uno de los ordenamientos que se complementan. Por tanto, basta con leer el art. 111-5 CCCat para darse cuenta que no vulnera ningún precepto constitucional, no sólo porque no excluye la aplicación supletoria del Código español, sino porque, bajo la fórmula genérica del derecho supletorio, queda plenamente subsumido.

En esta misma línea, el art. 111-4 CCCat, según el cual el Código civil de Cataluña es derecho común en Cataluña, tampoco sobrepasa las previsiones constitucionales sobre competencia de la Generalitat en materia civil, antes al contrario, se limita a reproducir lo que ya había afirmado la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1968, al resolver que el derecho civil catalán es, para los catalanes, su derecho común y, consecuentemente, que éste se debe aplicar de manera preferente al Código español, incluso en la supletoriedad del Código de comercio. De hecho, esto se ve reforzado, en cierta medida, por el art. 26.1 EAC, que dispone:

> *"[E]n matèria de la competència exclusiva de la Generalitat, el dret català és aplicable en el seu territori amb preferència a qualsevol altre".*

Desde esta perspectiva, y vistas las anteriores argumentaciones, no hace falta mencionar que la elección de la técnica de un código civil para Cataluña no puede suponer, por sí misma, ninguna invasión de las competencias del Estado, sino que la inconstitucionalidad sólo se puede predicar, si procede, de los preceptos determinados que, al regular las concretas instituciones invadan los límites señalados en el art. 149.1.8ª CE (y el art. 9.2 EAC). Además, la propia circunstancia de que en la petición subsidiaria de inconstitucionalidad, se excluyan aunque sólo sean seis preceptos de la impugnación juega a favor de esta interpretación y constituye un sólido argumento para que sea desestimada la pretensión de inconstitucionalidad de toda la Ley.

Atribuir al Código civil español la función de ser un límite competencial que impida que la Generalitat de Cataluña pueda aprobar un Código civil propio no tiene soporte normativo; ni la Constitución contiene ninguna previsión en este sentido, ni reserva ningún papel específico al Código español, más allá de considerarlo, como el resto del derecho estatal, de aplicación supletoria y sin perjuicio, claro está, de los preceptos que son de aplicación directa. En cualquier caso, la supletoriedad del derecho estatal y, por tanto, del código español, queda perfectamente preservada y garantizada por el art. 111-5 CCCat, que dispone:

> "*Les disposicions del dret civil de Catalunya s'apliquen amb preferència a qualsevol altres. El dret supletori només regeix en la mesura que no s'oposa a les disposicions del dret civil de Catalunya o als principis generals que l'informen*".

Pero no sólo el mencionado art. 111-5 CCCat se mantiene escrupulosamente dentro de los límites competenciales previstos en la Constitución, sino que además reproduce la misma regla que hasta ahora contenía la DF 4a. Sencillamente, donde la DF 4a se remitía al "*Codi civil* [español] *i altres lleis estatals*", el art. 111-5 CCCat lo ha sustituido, genéricamente, por el "*dret supletori*". Comparémoslo, sino con la redacción de la DF 4a según la que,

> "*[...]en el que no preveuen les disposicions del dret Civil de Catalunya regeixen supletòriament els preceptes del Codi Civil i de les altres lleis estatals de caràcter civil, en la mesura que no s'oposin a aquelles disposicions o als principis generals que informen l'ordenament jurídic català*"

De esto se hace eco también el preámbulo cuando afirma que el Título primero recoge y sistematiza los preceptos hasta ahora contenidos en el Título Preliminar y en las Disposiciones Adicionales segunda y cuarta de la Compilación. Por tanto, no es cierto que comporte "*[l]a creación de un sistema jurídico autónomo que inadmita cualquier grado de supletoriedad estatal*", sino que son muchos, todavía, los supuestos en los que el derecho estatal, y muy particularmente el Código civil español, debe entrar como supletorio del catalán. Esto no obsta que, teniendo en cuenta que entre las aspiraciones del legislador catalán está la de ir llenando todas las lagunas derivadas de la falta de desarrollo legislativo, se llegue finalmente a excluir totalmente la aplicación del derecho supletorio (en aquello en lo que la Generalitat no tiene competencia, el derecho estatal se aplicará directamente, no supletoriamente). Es decir, por la vía de llegar al máximo grado de desarrollo, el derecho catalán podría llegar a cubrir todas las materias civiles sobre las que tiene competencia, haciendo innecesaria la aplicación del derecho supletorio, lo que en ningún caso afecta la aplicación general y directa de las normas que regulan materias civiles que son competencia del Estado.

Así pues, descartado que el Código español sea un exponente del principio de la unidad legislativa, sólo nos queda analizar el argumento que basa la pretensión de inconstitucionalidad en el hecho de que el art. 111-1 incluya los principios generales dentro de las fuentes del derecho civil catalán, considerándola una norma de cierre que impide la aplicación supletoria del Código civil español. Entiendo que este precepto tampoco incurre en inconstitucionalidad ya que no dice nada que no dijera ya la Compilación. La mencionada DF 4a al afirmar que el Código civil español y las otras leyes estatales de carácter civil sólo se aplicaban en la medida en que no se opusieran al derecho catalán o a los principios generales que informan el ordenamiento jurídico

catalán, de hecho, ya estaba admitiendo que, en la Compilación, los principios generales eran fuente del derecho. La única referencia que expresamente no contenía aquella DF 4a era la jerarquización de la costumbre dentro de las fuentes del derecho civil catalán, y resulta que ahora que se incorpora expresamente en el art. 111-2.2 CCCat, éste es de los pocos preceptos que no ha sido objeto de impugnación. Toda una paradoja.

Pero lo más grave es que el recurso contenga omisiones muy flagrantes: una que ya he mencionado, es que no alude ni una sola vez a la Constitución republicana que es el antecedente inmediato del vigente art. 149.1.8ª CE que da buenos argumentos en contra de la extendida interpretación restrictiva; y otra que, aunque el debate argumentativo sobre la pretendida inconstitucionalidad se centra en la regulación de las fuentes del derecho que hace el Código Civil de Cataluña, el recurso no hace ni una sola referencia a que la competencia de la Generalitat para fijar el sistema de fuentes del derecho propio deriva del art. 149.1.8ª CE, según el que, en su determinación del Estado debe respetar *"las normas de derecho foral o especial"* y del art. 26.e EAC que reitera esa misma norma estableciendo que "*En la determinació de les fonts del dret civil, l'Estat respectarà les normes del dret civil català*". En fin, el derecho civil de Cataluña no sólo puede tener su propio sistema de fuentes, sino que mediante la técnica codificadora puede legítimamente pretender situarse –aunque de momento sea sólo de un modo casi formal- entre los ordenamientos plenamente normalizados. Con la Constitución en la mano, no encontramos ninguna razón para que esto no pueda ser así, sino que, contrariamente, se nos reconoce este derecho.